

1501465-45.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... dinheiro, nem anotação referente ao tráfico de drogas. Relatou que, realizada pesquisa pela qualificação do réu, constatou-se ser ele procurado pela Justiça. Narrou que, questionado sobre os fatos, o réu admitiu, informalmente, a realização do tráfico de drogas. Disse que somente o acusado estava no imóvel e consignou que não viu nenhum indivíduo evadir-se do imóvel quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501465-45.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-45.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVALDO FOSTINO DOMINGOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

EDVALDO FOSTINO DOMINGOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, tinha em depósito, para fins de tráfico, 10 porções de cocaína, uma porção de maconha e três porções de droga sintética, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi também apreendida no local uma balança de precisão.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos quanto ao apenamento e à fixação do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelos laudos de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que, ciente de que pesava contra si um mandado de prisão e sabendo de sua condição de procurado, saiu da residência em que morava com sua família por medo de retornar à prisão. Contou que, por intermédio do marido de sua prima, conseguiu um quarto nos fundos de uma casa, onde poderia se estabelecer até encontrar outro imóvel para residir com sua família. Alegou que, na data dos fatos, estava retornando da padaria quando policiais que passavam pelo local o abordaram. Contou que, diante de sua condição de procurado, forneceu aos policiais o nome de seu primo, porém sua verdadeira identidade foi por eles constatada. Disse que os policiais perguntaram se poderiam entrar no imóvel e, por nada haver na casa além de pertences como colchão, ventilador e fogão, franqueou-lhes a entrada. Contou que ingressou no imóvel com os dois policiais, que realizaram busca e nada encontraram. Disse que foi questionado sobre drogas, mas negou que tivesse entorpecentes. Alegou que os policiais pediram-lhe uma quantia em dinheiro para que não o levassem preso, mas disse aos policiais que não possuía o valor. Contou que foi conduzido à delegacia na qualidade de capturado em relação a fatos diversos, porém, na delegacia, viu que policiais retiraram uma mochila da viatura e, posteriormente apresentaram drogas, cuja propriedade lhe foi atribuída. Disse que o marido de sua prima, por meio de quem obteve o local para residir, chama-se Cristiano Silvestre e ele é o proprietário da adega, sendo que as pessoas que ali trabalham sabiam que residia no local dos fatos e de sua condição de procurado pela Justiça. Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida, além de não serem críveis, não encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A testemunha policial militar Danilo Fernando Alves de Sousa, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento com seu parceiro de farda quando um senhor, que não quis identificar-se, informou que, em determinado endereço, havia uma residência que estava vazia e, possivelmente, ali ficavam moradores de rua ou usuários de drogas e que, também ali, possivelmente ocorria o tráfico de drogas, informando, também, que naquele local havia fluxo diário de pessoas. Narrou que foram ao endereço indicado, ao lado do qual havia uma adega e, em contato com um rapaz que trabalhava nesse comércio, foram informados que não havia ninguém residindo no imóvel ao lado. Esclareceu que o acesso ao local dos fatos era feito por um corredor, cujo portão estava aberto, e, ao fundo, havia uma casa com alguns cômodos. Declarou que a porta da casa estava entreaberta e, empurrando-a, visualizou, de pronto, o réu sentado em um colchão, armazenando entorpecente em um saco plástico. Disse que, realizada busca pessoal, com o acusado nada foi encontrado, porém, sobre o colchão, havia uma pedra de cocaína, além de outras substâncias entorpecentes cuja espécie não recordou. Narrou que também foi apreendida no local dos fatos, sobre o colchão, uma balança. Não recordou se foi apreendida quantia em dinheiro, nem anotações relativas ao tráfico de drogas. Consignou que, após consulta pela identificação do réu, constatou que ele era procurado pela Justiça. Disse que somente o réu estava no imóvel e ele, informalmente, admitiu que estava vendendo drogas, fazendo a entrega dos entorpecentes a quem ligasse para ele. Relatou que não viu nenhuma pessoa empreender fuga do local. Disse que, na casa, havia geladeira e fogão e, no cômodo em que o réu estava, havia um colchão e um ventilador, além de roupas largadas. No mesmo sentido, a testemunha policial militar Rodrigo Faganello Bertazzo, ouvida em Juízo, narrou que realizava patrulhamento quando um homem, que não quis identificar-se, informou sobre o acentuado fluxo de pessoas que entravam e saíam de um beco, o que gerava desconfiança de que ali poderia estar ocorrendo a venda de

algo. Relatou que o local indicado pelo transeunte situava-se ao lado de uma adega, onde manteve contato com um rapaz que, indagado, informou que a casa ao lado estava abandonada. Declarou que entrou no beco e, ao fundo, havia uma casa em estado de abandono, sem porta, e ali visualizou o acusado sentado no chão, pesando drogas. Disse que foram localizadas naquele local uma pedra grande de cocaína, que o acusado fragmentava em pedaços para colocá-los em pequenos invólucros, além de uma pequena porção de maconha e uma balança de precisão. Declarou que não foi apreendida quantia em dinheiro, nem anotação referente ao tráfico de drogas. Relatou que, realizada pesquisa pela qualificação do réu, constatou-se ser ele procurado pela Justiça. Narrou que, questionado sobre os fatos, o réu admitiu, informalmente, a realização do tráfico de drogas. Disse que somente o acusado estava no imóvel e consignou que não viu nenhum indivíduo evadir-se do imóvel quando chegou à adega, esclarecendo que a casa situava-se ao fundo do beco. Relatou que, na casa, havia somente um colchão, sobre o qual o réu estava sentado. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos, assim como seu parceiro também não o conhecia.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a diligência ao local dos fatos, a abordagem do réu e a apreensão das drogas que o réu tinha em depósito.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).
No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.
2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).
Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).
3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).
4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.
5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente,

como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se

dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

A Defesa deixou de produzir prova que desqualificasse os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia.

Outrossim, as acusações feitas pelo acusado contra os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares, colhidos durante a instrução criminal, mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial, a identificação e abordagem do acusado e a localização dos entorpecentes, e encontram-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

As testemunhas policiais militares esclareceram pormenorizadamente as razões que ensejaram a diligência no local dos fatos, relatando que a notícia recebida por um transeunte que não quis identificar-se formalmente indicava o imóvel no local dos fatos, onde havia intenso fluxo de pessoas e onde poderia estar ocorrendo a venda de algum produto. Acrescentou a testemunha Danilo que o transeunte não identificado fez menção à possibilidade de, naquele local indicado, estar ocorrendo o tráfico de drogas.

Asseveraram que, para averiguação dos fatos noticiados, dirigiram-se ao local indicado, situado ao lado de um comércio, onde obtiveram a informação de que ninguém residiria naquele imóvel.

Afirmaram que o portão de acesso ao corredor estava aberto e, chegando à casa aos fundos, puderam visualizar o acusado sentado, manuseando drogas.

Consignou a testemunha Danilo que o réu estava sobre um colchão, onde havia uma balança, uma pedra de cocaína, além de outras substâncias, e acrescentou a testemunha Rodrigo que o réu fragmentava a pedra, que era grande, em pedaços que armazenava em pequenos invólucros. Consignou, ainda, Rodrigo, que também foi apreendida uma pequena porção de maconha e uma balança no local.

Afirmaram que somente o acusado estava na casa e não visualizaram nenhuma outra pessoa sair ou empreender fuga do local.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela combativa Defesa, não há dúvidas de que era o acusado o indivíduo que estava no interior da casa onde foram encontrados os entorpecentes, sendo ele o indivíduo que os policiais militares visualizaram manuseando a droga. Portanto, não há dúvidas de que era o acusado quem estava, de fato, realizando o tráfico de drogas no local e que a ele pertenciam os entorpecentes apreendidos.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada de que teria sido abordado pelos policiais ao lado de fora do imóvel e que, tendo os policiais constatado que havia fornecido a eles falsa identidade, permitiu a entrada dos policiais na casa, porém ali nada foi encontrado, mas, na delegacia, para onde foi conduzido em razão de sua condição de procurado pela Justiça, foram apresentados entorpecentes cuja propriedade lhe foi falsamente atribuída, não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos policiais militares encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais, que sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos, pois são absolutamente aptos e

suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da variedade e da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da grande quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e a balança foram apreendidas.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). Finalmente, não haveria se cogitar em nulidade da prova pela alegada “invasão a domicílio” cometida pelos policiais.

Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, visto que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

É a hipótese do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, de natureza permanente e, portanto, reitera-se, tem sua consumação protraída no tempo. A entrada dos policiais era justificada pela situação de flagrância constatada.

Note-se que, no presente caso, havia a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas no local dos fatos. Confira-se:

Como evidenciado pela prova colhida nos autos, a diligência no cômodo onde foram encontradas a considerável quantidade de drogas variadas não ocorreu de forma aleatória.

Havia notícia anterior acerca do tráfico de drogas. Os policiais ressaltaram que a diligência foi motivada por notícia dada por um transeunte, que indicava o local dos fatos, onde haveria intenso fluxo de pessoas, e onde, possivelmente, ocorreria o tráfico de drogas.

Asseveraram os policiais que, apurando com uma pessoa do comércio ao lado do local indicado que aquele imóvel estaria desocupado, ingressaram no corredor e, chegando na casa, puderam ver o acusado manuseando entorpecentes.

Não se pode alegar, portanto, qualquer tipo de conduta abusiva por parte dos policiais ao entrarem no local, nem que tenham agido de forma aleatória, repita-se. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 603.616/R0, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

Transcreve-se, a seguir, a mencionada tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida – Preliminar - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO - Presente in casu a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão pelos policiais sem mandado judicial. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial,

em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. Precedente do STF. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2140716-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) – PRELIMINAR DE NULIDADE – INVASÃO DE DOMÍLIO – Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME – Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tamaña a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO – Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Insurgência contra suposta violação ilegal de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi escorado em fundadas suspeitas de que lá se praticava crime, com confirmação decorrente da apreensão de considerável quantidade de drogas para o tráfico, segundo confissão. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, com fundamentação inidônea. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas de PEDRO a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e de ALEXANDRE a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. " (TJSP; Apelação Criminal 0003609-

60.2020.8.26.0302; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal -Prova ilícita em razão de invasão de domicílio Não cabimento Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão (...) (TJ-SP - APR: 15014712820208260599 SP 1501471-28.2020.8.26.0599, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 21/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021)

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de ilicitude probatória nos procedimentos que cercaram a prisão em flagrante consiste na violação do domicílio sem prévia investigação ou ordem judicial. Liminar deferida. 1. Ilicitude probatória não configurada. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Ação motivada por denúncia anônima que indicou o endereço e a pessoa responsável pelo armazenamento das drogas. Uma vez no local, os policiais avistaram o paciente que ao notar a aproximação da viatura correu para o interior do imóvel que havia sido referido na denúncia. Ilegalidade que não se mostra evidente. Necessidade de aprofundamento da questão ao longo da instrução. 2. Fumus comissi delicti dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Visibilidade e imediatidade da prática delituosa. Quadro de justa causa configurado. 3. Não demonstração do periculum libertatis. Quantidade de drogas pequena. Paciente primário. A ausência de comprovante de ocupação lícita não é, no caso dos autos, elemento suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Ausência de elementos indicativos da gravidade concreta. Precedentes. 4. Medida extrema que se apresenta desproporcional. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 22255992520208260000 SP 2225599-25.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 16/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020)

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça adota esse entendimento, conforme recentes decisões:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protraí-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. 2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior

encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência". 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína. 5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo que se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados

mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Por estas razões, não haveria que se falar em nulidade da prova.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, justifica-se o aumento da pena. Verifico, ainda, que o acusado é portador de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 40 (Processo nº 0000054-85.2015.8.26.0536) e 41/42 (Processo nº 0015324-65.2007.8.26.0590). Assim, fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 1/3, ficando ela estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o réu é reincidente pela prática de mesma espécie de delito, conforme certidão criminal de fls. 40/41 (Processo nº 0001638-56.2016.8.26.0536), motivo pelo qual aumento sua pena em 1/3, a qual resta fixada em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor já estabelecido.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa

circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. A pena deve ser acrescida de 1/6, ficando fixada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 1036 (mil e trinta e seis) dias-multa, no valor já estipulado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da considerável quantidade da droga apreendida, bem como da reincidência específica do acusado.

Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA SUPERIOR A 1 (UM) ANO. UMA RESTRITIVA E OUTRA DE MULTA MAIS BENÉFICA. IMPROCEDÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3. Não configura bis in idem a aferição desfavorável da natureza da droga (cocaína), na primeira etapa da dosimetria, para majorar a pena-base e a utilização da quantidade (567 gramas) na escolha da fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes do STJ e do STF). 4. Fixada a sanção corporal em patamar superior a 1 (um) ano, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritivas de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (Precedente). 5. Ordem não conhecida. (HC 386934 / SC HABEAS CORPUS 2017/0020104-9, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS , Quinta Turma, julgado em 16/03/2017 , PUBLIC 23/03/2017 - g.n.).

Da mesma forma, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização dos maus antecedentes ou reincidência para o aumento da pena nas primeiras fases da dosimetria e, ainda, suas considerações para fins de afastamento da redutora prevista na Lei de Drogas, posto que tal conjuntura, na primeira e segunda em relação à terceira etapa de dosagem das penas, possui natureza jurídica diversa.

Neste sentido, já decidiu o Pretório Excelso, confira-se:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os